

1501468-31.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... depurador de cinco anos, por furto, roubo e tráfico dentre elas, como se vê das certidões criminais às fls. 48/51. Por isso, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501468-31.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001055

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199929/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 19220375 - 03º D.P. DIADEMA, 2470/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2199929 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gean Kleber Moura de Souza

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GEAN KLEBER MOURA DE SOUZA, qualificado às fls. 05/07, está sendo processado como incurso artigo 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 24 de julho de 2021, por volta das 20h12, durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia da Covid-19, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Avenida São José, nº 26, Centro, nesta cidade de Diadema, tentou subtrair para ele, uma mochila e um tênis, mercadorias avaliada em R\$100,00 (fls. 08/09) e pertencentes à empresa Lojas Marisa.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fl.133/136). A denúncia foi recebida em 13/08/2021 (fl.)167, sem proposta de suspensão condicional do processo nem de acordo de não persecução penal dada à má personalidade do agente (fl.50). Citado (fl.190), foi-lhe nomeado Defensor Público

que ofertou defesa inicial às fls. 202/206. Foram ouvidos o representante da empresa vítima, uma testemunha arrolada pelas Partes, homologadas as desistências da oitiva do policial Regis, e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base bem acima do mínimo legal ante os péssimos antecedentes criminais do agente, com o aumento pelas agravantes da reincidência e da calamidade pública, mais a redução mínima pela tentativa, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Já o d. Defensor Público reiterou a tese da insignificância, e entendeu que o fato é atípico dada à posse lícita. No mérito, pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade e contrariedade da prova. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, afastando-se a agravante da calamidade pública por falta de nexo causal, com a redução máxima pela tentativa, fixando-se regime aberto ante a detração penal, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Afasto mais uma vez pedido defensivo de se considerar o princípio da insignificância ao presente caso, reiterando decisão de fls. 217/218, pois como já visto e decidido, o réu é reincidente e ainda possui péssimos antecedentes em crimes de natureza patrimonial, que indicam a habitualidade delitiva (fls. 48/51) a não justificar qualquer benesse. Tanto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Igualmente, este é o entendimento majoritário do e. STF: (...) 2. Reincidência do Recorrente assentada nas instâncias antecedentes. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 3. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. (HC N. 112.811-SP, RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA).

No mérito, a ação procede em parte, sendo hipótese de se afastar apenas a agravante da calamidade pública, como passo a expor.

A materialidade delitiva vem estampada nos autos de exibição e apreensão, e de avaliação de fls. 11/13, com o encontro das mercadorias ainda em poder do acusado. Ressalto que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP - AC - Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

A autoria é inconteste.

Wesley Guimarães (fl. 5), segurança da loja Marisa, ouvido em solo pré-processual, narrou que na data de hoje estava na porta do estabelecimento quando viu um indivíduo adentrar nesta, perto da hora de fechamento, com um sacolão de mercado cheio de produtos. Disse que acompanhou visualmente o indivíduo, observando à distância que este pegou uma mochila da loja e tentou colocar peças jeans dentro

desta. Ao perceber que estava sendo observado, desistiu de colocar as peças de jeans na mochila e saiu andando pela loja com a mochila nas costas e o sacolão de mercado nas mãos. Afirmou que o indivíduo saiu em direção à saída da loja, ocasião em que o abordou, questionando-o se ele iria sair com a mochila da loja nas costas, tendo este respondido que a mochila era dele e já havia entrado na loja com esta. Aduziu que diante deste impasse discutiram e o indivíduo ficou agressivo, tendo então que usar de força moderada para contê-lo. Afirmou que verificou que a mochila que o indivíduo portava estava com a etiqueta da loja. Por fim, disse que dentro do sacolão havia diversos tênis, a maioria com um pé só, sendo que apenas um reconheceu com certeza como sendo da sua loja, não tendo certeza quando aos demais itens, desconfiando de que alguns são produtos de furtos de outras lojas do centro.

Sob o crivo do contraditório Wesley reiterou que o indivíduo adentrou a loja e foi para o piso superior. Lá tentou subtrair produtos. Observou que ele estava escondido embaixo de uma arara de roupas e ele tentava colocar os produtos dentro da sacola, escondido ali. O réu o viu e tentou sair da loja. Foi abordado e disse que tentava furtar produtos, e com ele já estavam produtos de outras lojas. As mercadorias foram devolvidas porque ele disse que não podia pagar. O conduziu até a saída, onde ele tentou lhe agredir com golpes, o conteve, acionando a polícia militar. Reconhece o réu. Os produtos eram uma bolsa e um pé de tênis da marca própria. E ele também estava com outros produtos, vários tênis da Mizuno e perfumes de outras lojas.

Segundo relatos extrajudiciais dos policiais militares (fls. 06 e 07) foram acionados para atender uma ocorrência de furto a estabelecimento. Ao chegar ao local verificaram que o suposto furtador estava contido pela segurança do local. Diante deste cenário, dirigiram-se até esta Delegacia de Polícia trazendo o segurança do estabelecimento e o agente contido para a tomada das medidas cabíveis de polícia judiciária.

Perante o juiz imparcial o policial Lucas Nascimento, reiterou que o réu já estava detido e com mercadorias furtadas da loja. Ele falava coisas desconexas, aparentava estar embriagado. Reconhece o réu. Com ele haviam outros pés de tênis. O segurança disse que o réu entrou na loja e colocou peças na mochila da loja e tentou sair, mas foi contido.

O indiciado, extrajudicialmente (fl.08) respondeu que tomou algumas cervejas na data de hoje e acabou entrando na loja em questão, sem saber o motivo disto. Disse que colocou uma mochila da loja nas costas, mas que não pretendia furta-la, nem a outros bens. Quando aos tênis encontrados na sua posse, na sacola, disse que estavam com ele porque trabalha como vendedor da loja Centauro de São Bernardo do Campo, não sabendo justificar porque a maioria dos tênis estava com apenas um dos pés. Aduziu que possui dois filhos menores, os quais estão em casa com a sua esposa. Disse que tem algumas passagens criminais decorrentes de erros cometidos no passado.

Perante o juiz imparcial o acusado falou que entrou na loja para comprar uma mochila. Estava com dinheiro no bolso. Havia passado na casa do seu pai atrás do Extra. Bebeu whisky com ele e ganhou um frasco de perfume. Trocou de blusa e saiu. Na sacola estavam os pés de tênis da loja onde trabalhava e tinha que atingir meta, então pediu para liberar os pés para mostrar os modelos para uns amigos. Subiu para o segundo andar da loja Marisa e desceu com ele nas costas, para pagar, só que o segurança abordou dizendo que ele estava furtando. Estava até com dinheiro para isso. Não deixaram pagar a mochila que estava em suas costas, chamaram a polícia, e por isso ficou alterado. Não deu depoimento no DP, pois queria falar só em juízo. Não deixaram ligar para ninguém. Só conversou com o oficial de justiça e hoje com o Defensor Público e com a Defensora Pública em setembro dia 13 ou outubro. Já foi processado por vários crimes antes. E os fatos em tela só foi um mal entendido. Colocou a mochila nas costas e ficou disfarçando. Questionado sobre isso, disse que

colocou mal a palavra, que ficou experimentando. Não colocou tênis da Marisa na sacola, porque só tinha os da Mizuno e Oasics.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Ora, judicialmente o acusado trouxe versão diversa da prestada inicialmente, na qual havia dito que bebeu cerveja e que não sabe o motivo de ter entrado na loja, já que trabalhava na Centauro, sendo que em audiência alegou ter bebido whisky com seu pai, que entrou na loja para comprar uma mochila que estava precisando, e que trabalhava em outra loja que a não a citada, mas sequer arrolou seu pai ou algum empregador ou colega de trabalho para comprovar sua versão trazida hoje, que está em dissonância com o contexto probatório, inclusive. E ainda alegou ter colocado a mochila nas costas e disfarçou. Questionado sobre essa conduta, disse que usou a palavra errada, pois estava só experimentando.

Entretanto, não foi isso que o segurança da loja explicou. Segundo ele, o réu adentrou a loja e subiu para o primeiro piso onde pegou uma mochila, colocou nas costas e depois se escondeu embaixo de uma arara de roupas onde tentava colocar produtos da loja dentro daquela, mas assim que notou sua presença, tentou sair, mas foi contido por estar na posse de uma mochila de um tênis. Mas na hora da saída, o réu reagiu e então foi contido e a polícia acionada. Assim, não se alegue que o representante da empresa vítima tenha trazido versão contraditória com sua primeira declaração, pois o que se vê foi que em juízo, passados sete meses, ele foi mais conciso, não trouxe tantos detalhes, nem foi questionado pela Defesa. Portanto, entendendo que suas declarações devem ser consideradas como prova válida, estando em harmonia sobre itens primordiais e não secundários acerca do ocorrido, e estão em harmonia com o contexto probatório. Dito isso, afastar tese defensiva de fragilidade ou de contraditoriedade da prova.

Assim como não procede a tese de atipicidade da conduta pela posse lícita da res. Ora, o próprio acusado alegou ter posto a mochila nas costas e ter "disfarçado", o que segundo o segurança da loja tratou-se da conduta dele alegar que a mochila seria dele e que já teria entrado com ela, mas depois foi visto que ainda estava com a etiqueta do estabelecimento comercial, e o acusado tentava sair da loja em poder dela, sem efetuar o devido pagamento, alegando que não tinha dinheiro. Por isso o segurança aceitou que ele devolvesse e fosse embora, mas o réu reagiu e então foi contido, o que ao meu ver, ainda que tenha sido detido ainda no interior da loja, já havia passado o local do caixa, onde deveria ter pago pelo produto e, portanto, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, ante a pronta intervenção do segurança. Daí a tentativa do furto e não a atipicidade da conduta que contou com o dolo do agente, e prática de atos executórios do crime, não se tratando mais de posse lícita ao afirmar ao funcionário que a mochila era sua ao invés de já devolver as res sem questionar.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, e especialmente os péssimos antecedentes criminais do réu, quatro condenações definitivas passado o período depurador de cinco anos, por furto, roubo e tráfico dentre elas, como se vê das certidões criminais às fls. 48/51. Por isso, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, não há circunstância atenuante a se considerar, e sim a agravante da reincidência (condenação definitiva por roubo comprovada as fls. 50 e 74) a aumentar a pena em 1/6, para 01 ano e 09 meses de reclusão mais 17 dias-multa.

Quanto à agravante do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu como: dificuldade de policiamento, menor cuidado por parte da vítima, ou uma situação dramática pela qual passasse, incapacitando-a total ou parcialmente de defesa, a merecer maior grau de reprovabilidade da conduta, considerando que os comércios praticamente já retomaram suas atividades assim como a rotina vai retomando o normal. Ademais, não há prova de que o réu tenha se aproveitado das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19 para praticar o furto em tela (vide neste sentido: TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228).

Em terceira fase, sem causa de aumento de pena, e sim de diminuição pela tentativa, e opto pela redução de 2/3 até considerando o fato do réu ter sido abordado na saída da loja depois de ter sido flagrado colocando mercadorias dentro da mochila, que acabou tirando e levando apenas a mochila como se sua fosse, e ante à recuperação de todos os bens subtraídos, sem prejuízo patrimonial à loja, se modo que a pena resta em 07 meses de reclusão mais 05 dias-multa. Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência e os péssimos antecedentes do réu, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o semiaberto, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, sem possibilidade de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque ausente o requisito subjetivo, isto é, porque o réu é reincidente e possui antecedentes criminais específico, não sendo nem socialmente recomendável a aludida benesse.

Sobre o regime prisional mais gravoso, ainda, cito jurisprudência com a qual compartilho: (...) Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes (STJ, HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18/10/2016).

Dito isso, afasto pedido da Defesa de se fixar regime aberto dada à detração penal. E deixo de me manifestar sobre esse tema, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, até porque, ao meu ver, o art. 387 do CPP não está em conformidade com os princípios da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Contudo, permito, contudo, o recurso em liberdade, pelo tempo de prisão do acusado por esse processo, sete meses.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano, porque este não houve.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GEAN KLEBER MOURA DE SOUZA, qualificado às fls. 05/07, como incurso no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento total de 05

dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

Absolvo o réu das penas do art. 61, II, do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP. O sentenciado poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, expeça-se mandado de prisão se o caso, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, e intime-se o réu a paga-la em 10 dias.

Comunique-se a vítima. Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA